

<제07장 취소소송의 가구제.제02절 가처분>

[예상][7.02-2]거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 취소처분`을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 `가처분` 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음2) 특히 거부처분에 대한 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상 집행정지 제도로는 목적을 달성할 수 없는 이유와 가처분의 필요성 및 허용 여부에 대해 논하라.》

<문제7.2의 물음2> 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 수익적 처분을 신청하였으나 거부처분을 받아 이에 대한 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전 임시로 수익적 지위를 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <거부처분 취소소송에서 현행 행정소송법상 집행정지 제도의 한계와 가처분에 의한 임시적 권리구제의 필요성 및 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분에 대한 취소소송에서 가처분 제도의 적용 가능성과 그 인정 여부를 검토한다.

II. 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 흠결

1. 집행정지의 소극적 성격

- 집행정지는 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 멈추는 소극적인 구제 수단이다. 이는 처분이 발해지기 전의 상태로 되돌려 놓는 것에 불과하며, 신청인에게 새로운 법적 지위를 부여하거나 적극적인 이행을 명하는 기능은 없다.

2. 거부처분 집행정지의 무용성

(1) 신청 시 상태로의 복귀

- 거부처분의 효력을 정지시키면 처분이 없었던 것과 같은 상태가 된다. 즉, 乙이 수익적 처분을 신청한 직후의 상태로 돌아갈 뿐이며, 행정청 B가 乙에게 수익적 처분을 내린 것과 같은 효과는 발생하지 않는다.

(2) 재처분의무의 불준용

- "행정소송법 제23조"는 본안판결의 기속력 중 재처분의무("제30조 제2항")를 준용하고 있지 않다. 따라서 거부처분의 집행이 정지된다고 하더라도 행정청에게 임시로라도 수익적 처분을 하도록 강제할 법적 근거가 없다. 결국 乙은 판결 확정 전까지 아무런 실질적 이득을 얻지 못하게 된다.

III. 항고소송에서 민사소송법상 가처분의 필요성 및 허용 여부

1. 가처분의 필요성

- 거부처분이나 부작위와 같이 집행정지만으로는 권리구제의 실효성을 확보할 수 없는 영역에서 적극적 가구제 수단인 가처분의 필요성이 제기된다. 乙의 경우처럼 판결 확정 전까지 임시로 수익적 지위를 설정받아야 할 긴급한 필요가 있는 경우 가처분은 유일한 대안이 될 수 있다.

2. 학설 및 판례의 입장

(1) 학설의 대립

- 긍정설은 헌법상 재판받을 권리와 국민의 실효적 권리구제를 위해 "행정소송법 제8조 제2항"에 따라 가처분을 인정해야 한다고 주장한다. 반면, 부정설은 행정소송법이 집행정지만을 명시한 것은 가처분을 배제하려는 취지이며, 가처분을 허용할 경우 사법부가 행정권의 영역을 침해하여 권력분립 원칙에 반한다고 본다.

(2) 대법원 판례의 입장

- "판례"는 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 명확히 하고 있다. "대법원"은 "행정소송법 제23조"가 집행정지라는 특칙을 두고 있으므로 민사소송법상의 가처분이 개입할 여지가 없다고 판시한다. 특히 거부처분에 대한 가처분은 행정청의 1차적 판단권을 침해하는 것으로 보아 허용하지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 집행정지 신청 시의 한계

- 乙이 거부처분 취소소송에서 집행정지를 신청하여 승인받더라도, 이는 행정청 B가 乙의 신청을 거부했다는 사실을 잠정적으로 지우는 것에 불과하다. 乙이 원했던 수익적 처분의 효과(예 : 영업 허가 등)는 발생하지 않으므로, 乙은 본안 판결이 확정될 때까지 경제적 손실 등 위험에 노출된다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 판단

- "판례"의 입장에 따를 때, 乙이 제기한 가처분 신청은 항고소송에서의 가처분 부정 법리에 따라 부적법 각하될 운명에 있다. 乙이 주장하는 적극적 가구제의 필요성은 인정되나, 현행법 해석상 사법부가 행정청을 대신하여 임시 지위를 창설해 주는 것은 권력분립의 한계를 넘는 것으로 간주되기 때문이다.

V. 결론

- 거부처분 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상의 집행정지는 단순히 거부의 상태를 정지시킬 뿐 신청인에게 적극적인 권리 상태를 형성해 주지 못하므로 목적 달성에 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 적극적 가구제인 가처분이 필요하나, "대법원 판례"는 권력분립과 행정소송법의 특칙 우선을 이유로 항고소송에서의 가처분 준용을 부정하고 있다. 이러한 논의는 현행 가구제 제도의 불비로 인해 발생하는 거부처분 상대방의 권리구제 공백을 확인시켜 주며, 장차 행정소송법 개정 시 임시처분 제도의 명문화가 필요함을 시사한다.